

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035038-85.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: XERXES GUSMÃO

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da UNIÃO para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação 5030728-36.2024.4.02.5001 até a prolação da sentença de mérito, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5035038-85.2024.4.02.5001

500003474832 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035038-85.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: XERXES GUSMÃO

RELATÓRIO

1. UNIÃO interpôs o presente recurso como medida de urgência contra a decisão proferida na ação n. 5030728-36.2024.4.02.5001 (autos principais), em trâmite no Juízo Federal do 2º Juizado Especial de Vitória, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a União implementasse o piso de 8% (Resolução CNJ 495/23) e o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Em suas razões, alega, em síntese, que a questão destes autos envolve interesse de toda a magistratura do Tribunal Regional do Trabalho, de forma que deve ser reconhecida a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente feito. Afirma que a Medida Provisória n.º 1.570, de 26 de março de 1997, convertida na Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, amplia a aplicação das Leis n.º 4.348/1964, 5.021/1966 e 8.437/1992, vedando expressamente o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique concessão de benefícios a servidores públicos e, via de consequência, a seus descendentes, bem como em relação a decisões judiciais que esgotem, no todo ou em parte, o objeto das ações. Sustenta que, considerando o pedido formulado pela parte demandante, não pode a decisão judicial impor à União seu imediato cumprimento, com base em cognição sumária, se a própria sentença, fundada em cognição exauriente, deve aguardar o trânsito em julgado. Ressalta que todos os atos previstos no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 exsurgem como verdadeiras obrigações de fazer que, por acarretarem indissociáveis efeitos pecuniários de trato sucessivo, fogem à regra geral que autoriza a execução provisória, impedindo, pela mesma lógica, a antecipação dos efeitos da tutela e seu imediato acatamento quando condenada a Fazenda Pública. Argumenta que tal vedação, por certo, visa resguardar o Erário, não ocasionando prejuízo irreparável à parte autora, pois que esta, mesmo com a readequação empreendida em sua estrutura remuneratória, detém meios suficientes para arcar com sua sobrevivência, ficando garantido o pagamento retroativo, corrigido e acrescido de juros de mora, caso ao final venha a sair vencedora. Aduz que, na hipótese dos autos, está presente o chamado "periculum in mora" inverso, vez que, por se tratar de verba alimentar, é a União que dificilmente conseguirá reaver os valores entregues à parte recorrida em virtude da propalada irrepetibilidade das parcelas vindicadas, destacando que, por outro lado, no momento em que há norma processual que veda a execução provisória de sentença que importe uma das situações acima, perfeitamente enquadráveis nos presentes autos, conclui-se, necessariamente, que sua execução, revestida de tutela antecipatória também restará vedada.

3. Foram formalizados os seguintes pedidos ao final:

Por todo o exposto, preliminarmente, se requer a declaração de incompetência do Juízo e extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC e Enunciado FONAJEF 24.

Sucessivamente, diante da ausência de pressupostos processuais e dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela questionada, bem como da impossibilidade de imediato cumprimento da ordem, antes do trânsito em julgado, pugna a União seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo e, ao final, seja ele provido, cassando-se a antecipação dos efeitos da tutela que determinou o pagamento de auxílio-saúde em franco descompasso com o ordenamento jurídico vigente.

4. A decisão de ev. 03 deferiu a tutela de urgência para atribuir efeitos suspensivos à decisão agravada.

5. O autor apresentou contrarrazões alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, que, “pelas provas documentais anexas à inicial, é possível concluir que: (1) o(a) Recorrido(a) faz jus ao auxílio saúde, sempre considerando dependentes/cônjuge e o adicional previstos no art. 5º, §§2º, 4º, 5º, incisos I e II, §6º da Resolução CNJ nº 294/2019 c/c art. 6º e art. 196, ambos da CRFB/1988 c/c art. 230 da lei nº 8.112/1990; (2) desde 03/2023 (piso de 8%) e 05/2023 (demais hipóteses/direitos) a União NÃO efetua o pagamento/reembolso adequado dos valores, conforme informações fornecidas em contracheque; e (3) a administração não respeita as determinações do CNJ sobre o tema”. Ao final, pede que:

(a)Seja INADMITIDO/NÃO CONHECIDO o recurso da União, face a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 7º, I do R.I das Turmas Recursais6 c/c art. 932, III do CPC/20157, e em que fundamentado;

(b)Seja revista/reconsiderada a decisão proferida por este(a) ilustre relator(a) no Evento 03, de modo a INDEFERIR o pedido de tutela provisória recursal da UNIÃO, mantendo intocável a decisão recorrida a quo, em razão da LITERAL AFRONTA (pela União) ao disposto no art. 5º, §5º e §6º da Resolução CNJ nº 294/2019 (alterada pela Resolução CNJ nº 500/2023), e sob pena de GRAVE afronta/violação ao Direito Constitucional à saúde do Recorrido(a), na forma do art. 6º e art. 196, ambos da CRFB/1988, e pelas razões apresentadas acima;

(c)Seja INDEFERIDO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida, nos termos em que fundamentado;

(d)No mérito, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso da União, de modo a manter inalterada a decisão recorrida, nos termos em que fundamentado;

VOTO

6. Afasta-se a alegação do autor de que o recurso da União não deveria ser conhecido, porque houve impugnação, com estrutura argumentativa, aos fundamentos da decisão.

7. Conforme consignado na decisão de ev. 03:

4. O autor, juiz federal do trabalho, ajuizou a ação de que esta medida liminar é dependente objetivando a aplicação da Resolução CNJ 294/2019, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 500/2023, referente ao auxílio-saúde. Este foi o pedido formulado na inicial da demanda:

"i. Seja declarado/reconhecido o direito da autora, ao recebimento do auxílio saúde indenizatório em pecúnia e sob a forma de reembolso, na forma do art. 4º, IV da Resolução CNJ nº 294/2019 c/c art. 6º e art. 196, ambos da CRFB/1988 c/c art. 230 da lei nº 8.112/1990, e nos termos em que fundamentado;

ii. Seja a União condenada a implementar (obrigação de fazer) o reembolso despesas (auxílio saúde) a Autora, cônjuge e dependentes, nos termos da Resolução CNJ nº 294/2019, em especial o art. 5º, §3º (teto de 10%, ou ao menos o piso de 8% do subsídio do magistrado), §5º, I e II (quando atingidos, frisa-se), 6º (ressarcimento de despesas com medicamentos e serviços laboratoriais e hospitalares não custeados pelo respectivo plano de saúde e comprovados pelas respectivas notas fiscais em nome dos beneficiários), com os reflexos financeiros desde 03/2023 (teto/piso) e 05/2023 (demais hipóteses), nos termos em que fundamentado;

iii. Seja a União condenada ao pagamento de indenização por Danos Materiais em favor do(a) Autor(a), no valor histórico e já apurado de R\$ 33.552,42 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), se V. Exª considerar como devido o TETO de 10%, ou ao menos prejuízo material histórico de R\$ 23.757,76 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) se V. Exª considerar como devido o PISO de 8%, tudo apurado SÓ no período de 03/2023 até 09/2024, e SEM prejuízo a condenação da União ao pagamento dos valores vincendos, por ser uma obrigação de trato sucessivo, a ser apurado em cumprimento de sentença, tudo com juros e correção monetária na forma determinada pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal (ou seja, SELIC, na forma do Art. 3º da EC nº 113/2021), e nos termos em que fundamentado."

5. A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a União implementasse o piso de 8% (Resolução CNJ 495/23) e o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias, sob os seguintes fundamentos:

O autor, Juiz Federal do Trabalho, requer a aplicação da Resolução CNJ 294/19, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 495/23 e pela Resolução CNJ 500/23, todas referentes ao auxílio saúde. Há pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer. O pedido referente à obrigação de pagar será analisado apenas em sede de cognição exauriente. Por sua vez, no que se refere à obrigação de fazer, há pedido de tutela provisória, tanto na modalidade tutela de urgência (art. 300 do CPC), quanto na modalidade tutela de evidência (art. 311 do CPC). A União foi intimada previamente para se manifestar sobre as tutelas provisórias, tendo apresentado manifestação apenas quanto à tutela de urgência, nada mencionado quanto à tutela de evidência.

Creio não haver dúvidas sobre o direito em si. A autora faz jus ao auxílio saúde (art. 4º, IV da Resolução CNJ 294/19). Não havia previsão de limite mínimo, mas apenas de limite máximo (10% do subsídio). Com a edição da Resolução CNJ 495/23, foi fixado limite mínimo de 8%. E mais. Com a edição da Resolução 500/23 foi fixado aumento de 50% no valor a ser pago, para os magistrados com mais de 50 anos ou com doenças graves.

Passo, agora, a analisar a partir de que momento o piso de 8% (Resolução CNJ 495/23) e o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23) deveriam ser implementados (sem análise, nesse momento, ao direito de eventuais atrasados). Senão vejamos.

A Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) foi publicada em 03.04.2023 e fixou em seu art. 2º que "O piso a ser observado para efeito de reembolso de auxílio saúde, a que alude a nova redação do §3º do art. 5º da Resolução CNJ n. 294/2019, deverá ser implementado pelos tribunais que optarem por manter essa modalidade de assistência à saúde complementar dos magistrados, até exercício financeiro seguinte ao da publicação desta Resolução". Observo, portanto, que a Resolução em tela fixou implemento do piso do auxílio saúde em 2024, mas não fixou se tal implemento deveria ocorrer no início ou até o final de 2024. Em adendo nada foi fixado sobre a recomposição orçamentária correspondente.

Por sua vez, a Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) foi publicada em 29.05.2023 e fixou em seu art. 2º que "Os Tribunais deverão promover a necessária recomposição orçamentária para a implementação do disposto no presente ato até o final do exercício financeiro seguinte ao da publicação desta Resolução". A Resolução em tela nada mencionou sobre a implementação do benefício, mas fixou prazo até o final de 2024 para a recomposição orçamentária correspondente.

Para execução plena de ambas Resoluções, há dois marcos temporais sensíveis que precisam ser explicitados: implementação financeira e recomposição orçamentária. A Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) prevê prazo de implementação, mas nada menciona sobre a recomposição orçamentária. Por sua vez, com relação à Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) o cenário é o contrário: nada foi mencionado sobre a implementação, mas foi fixado prazo para a recomposição orçamentária. Há, portanto, lacunas a serem supridas. Dessa forma, com base na analogia, creio que deva utilizar os parâmetros temporais de ambas Resoluções para suprirem, mutuamente, as lacunas existentes.

Antes, porém, registro que a implementação da Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) deva ocorrer no início de 2024 e não no final de tal exercício. Nada impede que a implementação seja efetivada no final do exercício. Mas a falta de regra explícita quanto à data de implementação, indica que a mesma deva ocorrer no início do exercício financeiro. E assim afirmo com base no princípio da anualidade na esfera financeira (art. 34 da Lei 4.320/64).

Assim, a implementação da Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) e da Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) deve ocorrer no início do exercício de 2024. Por sua vez, a recomposição orçamentária referente a ambas Resoluções deve ocorrer até o final do exercício de 2024. Importante registrar que a execução orçamentária e a execução financeira, embora atreladas, não se confundem, podendo ocorrer em marcos temporais diversos do mesmo exercício, em função da peculiaridade do tema (Lei 4.320/64).

Estabelecida a interpretação acima, sobre aos marcos temporais das Resoluções aqui envolvidas, estou convencido de que a União não se encontra em mora. Pelo menos não ainda. Explico. Mesmo que se venha a reconhecer o implemento das condições com a vigência dos Atos do CNJ (e eventual direito a atrasados), o benefício em tela só é exigível financeiramente a partir do primeiro pagamento do exercício seguinte à edição das Resoluções, ou seja, em 2024. Assim, apenas se não houver pagamento do auxílio saúde com os valores reajustados (piso de 8% e aumento de 50% para maiores de 50 anos), a partir do dia 20.01.2024 (data de pagamento da magistratura Federal) é que ocorrerá mora da União.

Seja como for, constatei que a União não impugnou objetivamente o direito ao benefício. E talvez nem pudesse. Afinal, o benefício foi criado pelo CNJ, que é órgão de controle da própria União, em relação ao Judiciário. Seria um paradoxo a União discordar dela própria. Não obstante, a União também não apresentou, em sua manifestação, nenhuma informação sobre a data da efetiva implementação dos benefícios aqui analisados. E tal informação seria exigível com base no princípio do planejamento (art. 174 da CR/88). Parece-me razoável, portanto, considerar que o pleno exercício do direito em tela ainda não se encontra incontroverso, sob a ótica da implementação financeira. Logo, há risco de dano, sendo prudente a intervenção do Judiciário, a teor do inciso XXXV do art. 5º da CR/88.

A matéria também me parece sensível, eis que abarca garantia à saúde dos magistrados, em especial aqueles com mais de 50 anos. E a qualidade de saúde dos membros do Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, enquanto efetividade e eficiência do exercício de um dos poderes da República. Há, portanto, interesse público difuso no sentido de que os magistrados tenham sua saúde controlada, para bem exercer suas atribuições constitucionais. Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois a autora, na qualidade de Juíza Federal, é solvente.

Isto posto, DEFIRO AMBOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA. Defiro antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC). De forma independente, também defiro tutela de evidência (art. 311 do CPC). Para ambas tutelas provisórias, determino que a União implemente o piso de 8% (Resolução CNJ 495/23) e o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo astreintes no valor de metade da diferença envolvida, para cada mês de eventual atraso no cumprimento desta ordem. Intimem-se. Cite-se.

6. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais federais para processar e julgar a demanda. O STF tem entendimento no sentido de que:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que **não** se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito **exclusivamente** à Magistratura. II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, **a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juizes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa.** III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AO 1840 AgR). (Sem negrito no original)

AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal **depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.** Precedentes. 2. Ação Originária não conhecida, determinando-se a devolução dos autos à origem. (STF, Segunda Turma, AO 2126). (Sem negrito no original)

7. Ultrapassada essa questão, verifica-se que, com efeito, o art. 1º da Lei n. 9.494/1997 estabeleceu a impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que objetive reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/1992 dispõe em seu art. 1º, § 3º, que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 4/DF, firmou entendimento pela constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 9.494/1997, que excluiu, taxativamente, hipóteses de antecipação de tutela contra o Poder Público: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas.

9. Dessa forma, embora haja probabilidade acerca do direito da parte recorrida, ante a documentação jungida aos autos, sua concessão em sede de antecipação de tutela, encontra óbice na Lei 9.494/1997.

10. Como bem destacou a parte recorrente, é notório o *periculum in mora* inverso, devido ao rígido modelo de concessão de medidas liminares em face do Poder Público, previsto nas Leis n.º 9.494/1997 e 8.437/1992.

8. Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão tomados como razões de decidir para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação 5030728-36.2024.4.02.5001, ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da UNIÃO para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação 5030728-36.2024.4.02.5001 até a prolação da sentença de mérito.